

1501464-97.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501464-97.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501464-97.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

AMANDA GONÇALVES PAIVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

ALEX ANTUNES DE SOUZA, AMANDA GONÇALVES PAIVA e LUCAS CRUZEIRO GIUFFRIDA, qualificados no autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 35, caput, c.c. art. 33, caput, c.c art. 40, III e V, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, porque por tempo indeterminado e até o dia 31 de maio de 2021, os acusados associaram-se para o fim de praticar narcotráfico na cidade. Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta das 18:15 horas, na Rodovia Presidente Dutra, altura do KM 204, bairro Jardim Jóia, nesta cidade, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso, transportavam consigo para fins de tráfico, 1 tablete de cocaína, contendo massa líquida de 1001,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, droga essa que causa dependência física e psíquica.

Narra a acusação que os acusados teriam se unido para a prática de crime de tráfico de drogas e iriam realizar o transporte de drogas até Jequitinhonha/MG, onde ocorreria a venda. Policiais rodoviários federais abordaram um ônibus de viagem da empresa Água Branca, com destino à Vitória da Conquista/BA, e que tinha como origem

a capital de São Paulo. Foi realizada a busca no interior do veículo e com Amanda foi encontrada, no interior da mochila, a quantidade de droga. A acusada informou que comprou a droga por R\$ 9.000,00 em São Paulo e que venderia em Jequitinhonha, pelo valor de R\$ 40.000,00. Alex e Lucas eram os responsáveis por auxiliá-la na compra e transporte do entorpecente até o destino. Foi apreendida também a quantia de R\$ 175,00.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01/02. Boletim de Ocorrência às fls.09/11. Auto de exibição e apreensão às fls.21/22. Laudo de constatação (fls.38/40).

Em audiência de custódia (fls. 73/75) foi convertida a prisão em flagrante dos acusados.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 122/125 e 141/148.

A denúncia foi recebida em 13/10/2021, às fls. 154/155.

Laudo de exame toxicológico às fls. 202/210.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 217/222).

A decisão de fls. 265/268 manteve a prisão preventiva dos acusados Alex e Lucas, revogando, contudo, a prisão preventiva da ré Amanda.

O Ministério Público em alegações finais de fls. 328/348, pugnou pela parcial procedência da denúncia, condenando-se os réus pelo delito de tráfico, mas afirmou que não se comprovou o delito de associação para fins de tráfico. Quanto à dosimetria, alegou que nos termos do art. 42 da Lei de drogas, havendo tablete de cocaína encontrado, deve a pena ser exasperada. Sustentou que a ré confessou o delito e que restou caracterizada a causa de aumento de transporte da droga para outro Estado da Federação. Alegou que não deve incidir a causa de aumento do art. 40, III, da lei de Drogas, pois não houve efetiva comercialização da droga no ônibus coletivo. Altercou que a ré Amanda é primária e faz jus ao reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo incabível a substituição da pena caso haja a pena superior a 4 anos. Em relação ao corréu Alex, afirmou que deve a pena ser exasperada por se tratar de tráfico de cocaína. Alegou que o acusado é reincidente, e que há causa de aumento por ser destinada a droga a outro Estado da Federação, não devendo ocorrer o reconhecimento de causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Sustentou ser inaplicável o reconhecimento de tráfico privilegiado e que o regime inicial deve ser o fechado. Em relação ao réu Lucas, repetiu o pedido de exasperação em primeira fase pela natureza da droga, assim como de causa de aumento por se destinar a outro Estado. Argumentou que o acusado confessou que sabia do transporte, por Amanda, de droga, e que incide a atenuante. Aduziu que não se opõe ao reconhecimento de tráfico privilegiado ao réu Lucas, sendo incabível a substituição caso a pena supere quatro anos.

Em alegações finais de fls. 349/355 a defesa do réu Lucas alegando que o réu não realizou quaisquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de drogas, sendo sua conduta atípica. Afirmou que o réu não pode ser visto como traficante. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de tráfico privilegiado, sendo revogada a sua prisão preventiva. Pugnou por fixação de regime aberto.

A decisão de fls. 356/357 revogou a prisão preventiva do acusado Lucas.

A ré Amanda apresentou alegações finais de fls. 370/380, requerendo sua absolvição pelo delito de associação para fins de tráfico. Requereu que seja aplicada a pena no mínimo legal, reconhecendo-se a confissão como atenuante e o benefício do tráfico privilegiado. Pugnou pela realização de detração.

O acusado Alex apresentou alegações finais de fls. 381/391, pugnando pela absolvição do acusado por falta de provas. Aduziu que o acusado não cometeu o delito de associação para fins de tráfico. Alegou que a corré Amanda assumiu a posse da droga. Requereu, subsidiariamente, a pena no mínimo legal, com reconhecimento de tráfico privilegiado e aplicação de regime aberto. Pugnou pela substituição da pena por restritiva de direitos, assim como a detração.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria dos acusados pelo cometimento de delito de tráfico de drogas restou satisfatoriamente comprovada.

Em relação ao delito de associação para fins de tráfico inexistem provas de materialidade e autoria delitiva.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Leandro da Silva declarou que é policial rodoviário federal e afirmou que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento na Rodovia Pres. Dutra e a abordaram o ônibus que ia para Vitória da Conquista. Com a acusada foi localizada a quantidade de droga. Afirmou que havia um quilo de cocaína. Ela assumiu a propriedade de drogas e falou que isso seria vendido em Jequitinhonha. Ganharia R\$ 1.000,00 para levar e ganharia R\$ 40.000,00 na cidade de destino pela venda. Afirmou que ela estava com o namorado Alex e outro rapaz, que foi quem fez contatos com quem entregou a droga. Afirmou que a ré tinha a bagagem de mão junto a ela no ônibus. Foi identificada a mochila como sendo da ré. Ela deixou que olhassem a bagagem e colaborou com a abordagem, respondendo perguntas e sendo tranquila. Disse que a acusada confessou que a droga era de posse dela. O policial Eduardo estava com ele na abordagem. A ré disse que foi buscar a droga em São Paulo. Ela aparentava não conhecer São Paulo. Afirmou que somente um rapaz que viajava juntos tinha celular e a ré confirmou que os corréus sabiam que ela levava drogas para outra cidade. Afirmou que não se recorda se algo de relevante havia com Lucas além do celular.

A testemunha Eduardo Arjona disse que é policial rodoviário federal. Afirmou que no dia dos fatos estava fazendo comando e pararam o ônibus. Encontraram com a ré um kg de cocaína. Ela assumiu que comprou a droga em São Paulo, teria pago R\$ 9.000,00 e venderia em Jequitinhonha por R\$ 40.000,00. Alex era namorado dela e Lucas seria o responsável por indicar onde ela encontraria a droga em São Paulo. Todos vieram para São Paulo para comprar as drogas e voltar. A abordagem foi de rotina e a bagagem da ré com a droga era de mão, na posse da ré. Afirmou que ela somente informou que era sua a droga após a vistoria. A ré confirmou que ia vender a droga em Minas Gerais. Informou que somente a ré estava na posse da droga, "acima dela e entre as pernas dela".

O acusado Alex Antunes declarou em interrogatório judicial que tem 25 anos, estudou até oitava série, é servente de pedreiro, já teve carteira assinada e ganhava R\$ 1.200,00 por mês. Tem uma filha e é namorado da Amanda. A filha mora com a mãe e tem dois anos. Em relação aos fatos, disse que foi com sua namorada Amanda para São Paulo e iriam passear. Quando ela chegou em Arujá soube que ela tinha drogas. Não

sabia que ela viria buscar drogas. Soube que ela tinha drogas quando houve a parada do ônibus. Em São Paulo ficaram passeando e não sabe dizer onde, pois não conhece nada. Acha que foi no Grajaú. Sua namorada ficou conversando com um pessoal, tomaram cerveja e e retornaram ao hotel, depois iriam para Minas Gerais. Ela pegou a droga. Perguntado se não sabia de nada, disse que sabia. Depois confirmou que sabia que ela possuía drogas, o que ocorreu em São Paulo. Perguntado a razão de não ter ido embora após ela contar que tinha drogas, disse que não foi por "necessidade". Disse que estavam passando necessidades, não tendo emprego. Perguntado se então confirmava que pegou drogas com ela e teria benefício, disse que ela estava precisando e veio ajuda-la. Ela avisou "aqui" sobre as drogas. Afirmou que primeiro ela lhe chamou para passear e em São Paulo contou das drogas, e concordou por ela estar precisando. Narrou que não vê sua filha há um ano. Está difícil em São Paulo e tudo não valeu a pena. Quer uma oportunidade e pede que a juíza a ajude pois a cadeia não é lugar de gente, não desejando isso a ninguém.

O acusado Lucas Cruzeiro Giuffrida declarou em interrogatório judicial que tem 32 anos, é designer gráfico, já teve vários empregos e era free lancer quando foi preso. Estudou até segundo grau incompleto. É casado e não tem filhos. Não foi processado antes. Disse que no dia dos fatos, veio com Amanda e Alex à São Paulo, vieram ver a Andreia e queria se reconciliar com ela. Atualmente é casado com ela. Veio com Amanda e Alex. Amanda queria ir "nas quebradas". Sabia que era algo relacionado à drogas e mostrou o local onde ela compraria a droga. Não ia pegar nada e só estava junto com ela. Disse que como a conhecia somente quis mostrar o local para ela. Estava passeando apenas e mostrou a ela outros lugares que passaram, como o Shopping, feira do Brás, e outros lugares. Passaram bastante em São Paulo. Ficou em São Paulo por cerca de 5 dias, mas estava com Andreia e encontrava os corréus para passearem. Afirmou que sabia que a Amanda queria comprar drogas. Afirmou que sabia que ela voltava com drogas no ônibus e se arrepende disso. Narrou que levou a acusado aos locais onde ela poderia comprar drogas em São Paulo e não ia ganhar nada com isso, estava apenas "curtindo" mesmo. É usuário de drogas e depois de um ano preso, está sem usar drogas e quer abandonar. Usa cocaína e maconha. Está muito arrependido de ter feito isso, tem saudades de sua família e a prisão é um inferno. Aprendeu com seu erro e não vai se repetir algo assim.

A ré Amanda Gonçalves Paiva declarou em interrogatório judicial que tem 29 anos, é aposentada por deficiência no braço. Não tem filhos e mora junto com o Alex. Disse que estudou até o segundo grau incompleto. Nunca foi processada antes. Em relação aos fatos, declarou que os fatos são verdadeiros. A droga estava na sua mochila, no ônibus, e estava sendo paga para buscar por receberia R\$ 1.000,00 e mais despesas. Seu pai tem câncer e queria ajudar sua família. Um cara em Jequitinhonha, vulgo "Gude", fez a proposta e aceitou. Afirmou que o Alex não sabia e Lucas conhecia São Paulo e mostrou locais onde poderia comprar drogas. O Lucas lhe levou ao local em que ela poderia comprar drogas, e como ele vinha ver a namorada, ele veio junto. Vieram e estavam voltando juntos. Sem o Lucas não saberia onde comprar a droga. O Alex é seu companheiro e falou a ele que iriam passear em São Paulo com Lucas. Pegou a droga no centro de São Paulo. Afirmou que ficaram na casa da namorada do Lucas quando vieram para São Paulo. Declarou que comprou a droga no centro e Alex não foi com ela. Foi somente com Lucas. Seu marido confia nela e deixou que fosse somente com Lucas em outro local, onde comprou as drogas. Saiu com o Lucas e o Alex "nem sabia", ficando só na casa. Falou para o Alex que ia sair com Lucas e ele não perguntou onde iriam. Foi passear no Brás e foi lá comprar a droga. Não sabe se o centro é longe do Brás, pois não conhece São Paulo. Afirmou que veio num dia e voltou no outro, não ficando muitos dias em São Paulo. Ao final disse que o Alex sabia e foi comprar as drogas com ela e Lucas. Não tinha vindo para São Paulo e não sabe diferenciar o centro do Brás. Afirmou que veio num dia e voltou no outro e demorou duas horas entre a casa da namorada de Lucas e o local em que comprou as drogas. Está presa há um ano, não tem parentes em São Paulo. Está arrependida e não valeu a pena o que aconteceu, querendo oportunidade para voltar à família.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De início, impõe-se absolver os réus pelo crime de associação para o tráfico, conforme requereu o próprio Órgão Ministerial em sede de alegações finais.

Isto porque, não restou devidamente demonstrado no caso em tela a prática do delito de associação para o tráfico, eis que os elementos probatórios são insuficientes à certeza de sua ocorrência.

Como é cediço, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirma Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

“Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” E mais: “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.”

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação, não há como se imputar aos acusados a prática do crime em questão, não tendo, desta feita, se desincumbido o Ministério Público do ônus probandi que lhe é imposto.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343.2006”. (HC 349837/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 03.05.2016. No mesmo sentido REsp 1501842/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05.04.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013, undefined)

Como mencionado alhures, mesmo que entendêssemos estarmos diante de alguns indícios de associação, isso não deve bastar para caracterizar a culpabilidade dos réus pelo delito em questão, especialmente quando toda a investigação não veio acompanhada de uma apuração mais rigorosa destas circunstâncias.

No caso, pode-se até cogitar de probabilidade do crime de associação, mas o fato é que, "no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio." (RT 619/267).

Outrossim, para configuração do delito de associação não se exige que os componentes da associação se conheçam e que haja nítida divisão de funções. Basta, apenas, que a associação vise à prática de um número incerto de crime, por tempo indeterminado (elemento subjetivo do tipo). No caso dos autos, todavia, a presença de vínculo estável e psicológico entre os réus não restou evidenciada pelas provas produzidas.

Registre-se que não houve investigação prévia sobre a atuação dos acusados que pudesse confirmar o vínculo associativo descrito na exordial acusatória. Ademais, os réus negaram a associação.

Ainda, não foram encontrados com os acusados anotações, balança ou outros insumos que pudessem revelar ou confirmar uma ligação estável e permanente entre eles para prática reiterada de crimes, nem mesmo de tráfico.

Quanto ao delito de tráfico, como já referido alhures, a conclusão é diversa, já que há prova suficiente para a condenação dos acusados.

O laudo pericial (fls. 208/210) comprovou a natureza da droga encontrada, indicando que o material apreendido consistia de fato em cocaína, com maior poder vulnerante.

Em seus interrogatórios, como se pode observar, os réus Alex e Lucas negaram ter realizado o delito de tráfico de drogas. O réu Lucas afirmou que indicou à Amanda onde ela poderia adquirir drogas na cidade de São Paulo. Já Alex disse que somente acompanhava a acusada e que ela adquiria drogas por "necessidade". Ambos alegam que a ré comprou a droga e iria vender em outra cidade.

A ré Amanda, por seu turno, confessou em parte a prática delitiva em interrogatório judicial, confirmando que teria se deslocado de Jequitinhonha, Minas Gerais, para São Paulo, com o namorado e o Lucas, afirmando que tinha a intenção de comprar drogas. Alegou que receberia R\$ 1.000,00 pelo transporte.

Em delegacia todos os acusados permaneceram em silêncio (fl. 06/08).

Os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo confirmaram que a ré trazia consigo, numa mochila, a cocaína encontrada, tendo confessado a eles o tráfico de drogas, informando-lhes que teria adquirido a droga por R\$ 9.000,00 e a venderia por R\$ 40.000,00, em Jequitinhonha, Minas Gerais. Informaram os policiais que os réus Alex e Lucas sabiam que havia drogas com a ré, sendo Lucas quem teria indicado o local para aquisição do entorpecente.

A conduta da ré Amanda não se resumiu à condição de mula do tráfico, pois segundo as testemunhas ouvidas, ela confessou que venderia a droga em Jequitinhonha e ganharia R\$ 40.000,00, tendo, portanto, adquirido a droga para venda a terceiros em outro estado da federação.

Portanto, inexistem dúvidas de cometimento de delito pelos acusados, devendo ser afastada a alegação da defesa do réu Lucas de que ele não teria praticado qualquer conduta descrita no tipo penal de tráfico de drogas.

Preconiza o art. 33, "caput", da Lei de Drogas que comete o delito quem "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Os acusados acompanharam a acusada Amanda a todo momento, desde a vinda para a cidade de São Paulo, passando pela compra da droga na região central daquela cidade e no percurso de volta com a cocaína, quando foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. Deste modo, é nítido que houve a anuência dos acusados com a conduta de tráfico de drogas, tendo eles realizado os verbos do tipo na modalidade "adquirir" e "transportar".

E não é só, o próprio acusado Alex em seu interrogatório judicial, ao ser inquirido sobre a razão de ter permanecido ao lado da ré após saber que ela estava adquirindo drogas, afirmou que ficou "por necessidade", dando a entender que tal "necessidade" era sua e não somente de Amanda.

Dessarte, também não é crível que os acusados não teriam qualquer ganho ou retorno financeiro pela conduta de indicar onde poderia ser comprada a droga, acompanhá-la na aquisição e transportar o entorpecente em ônibus coletivo para outro estado da federação.

Ainda, a acusada Amanda afirmou que sem Lucas, não saberia onde adquirir a droga, sendo sua atuação na empreitada criminosa, portanto, fundamental para a aquisição do entorpecente.

Nota-se, como dito, que a ré Amanda durante o seu interrogatório judicial primeiro negou que Alex tinha conhecimento de que ia comprar drogas, mas ao final confirmou que ele era sabedor da aquisição de drogas.

Sobre o reconhecimento de dolo em casos como o presente, já se manifestou a jurisprudência:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de transportar 150 porções de cocaína (26g). Comprovação da materialidade delitiva. Autoria comprovada quanto a JHONATHAN e RAFAEL. Agentes que transportaram o entorpecente a fim de entregá-lo a terceiros. Dolo comprovado pelas circunstâncias dos fatos. Negativas contraditórias e inverossímeis. Absolvição de LUIZ EDUARDO. Falta de provas suficientes quanto a autoria delitiva. Sentença reformada. Penas reduzidas. Apelo de LUIZ EDUARDO provido, parcialmente providos os demais. (TJSP; Apelação Criminal 1500788-20.2020.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2022; Data de Registro: 16/09/2022)

Em contrário sensu, demonstrando-se que o conhecimento de que a corré transportava drogas evidencia a conduta dolosa:

RECEPÇÃO DOLOSA. Configuração. Conduta de conduzir caminhão e carreta carregada com 24.706Kg de queijo, que sabiam ser produto de roubo. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de dolo isolada. Ciência da origem ilícita demonstrada pelas investigações policiais e circunstâncias do flagrante. Absolvição pelo delito de TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Inconformismo acusatório. Não cabimento de condenação por infração à Lei nº 11.343/06. Ausência de provas sobre o dolo da conduta. Porção de maconha (952,7g) encontrada em local de difícil acesso na lataria do caminhão. Nenhum indício de que os réus soubessem da droga. Sentença mantida. Penas bem dosadas. Terceiro interessado. Restituição de veículo apreendido. Bem de origem lícita que não interessa mais ao processo. Liberação

deferida. Apelos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 0071894-95.2014.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2016; Data de Registro: 06/07/2016).

Outrossim, da análise dos autos, e à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir serem os réus integrantes de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/2006 ao caso em questão aos acusados que fizeram jus ao benefício.

A acusada Amanda e o réu Lucas são primários, (fls. 261/261 2 311/312), devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré ostenta bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa. Observo que embora o réu Lucas tenha condenação por delito de roubo, com sentença proferida em 01/04/2020, não há nos autos informação de trânsito em julgado de tal decisão.

O acusado Alex possui condenação anterior por delito de tráfico de drogas, transitado em julgado (fls. 304/305), não fazendo jus ao benefício legal.

No mais, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente os réus de pena, sendo a ação foi culpável, reprovável, pois os réus eram (e ainda são) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR AMANDA GONÇALVES PAIVA e LUCAS CRUZEIRO GIUFFRIDA como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c §4º, e art. 40, inciso V, tudo da Lei 11.343/06 e CONDENAR ALEX ANTUNES DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. ABSOLVO todos os acusados do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

A) Em relação à ré Amanda Gonçalves Paiva:

Verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. A ré não ostenta maus antecedentes (fls. 261/262). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias se revelam desfavoráveis, diante da localização de cerca de um quilo de cocaína com a acusada, droga de maior poder vulnerante, considerando o teor do art. 42, da Lei 11.343/06.

Diante disso, imponho à ré a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena da ré, atingindo a pena intermediária o patamar de 5 anos, 02 meses e 15 dias, além de 468 dias-multa.

Não é caso de incidência da causa de aumento do art. 40, III, da lei 11.343/06, uma vez que para o reconhecimento desta não basta que a ré traga consigo drogas em transporte público, devendo ocorrer efetivo ato de comércio no interior do ônibus, como bem argumentou o Ministério Público em alegações finais.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos das Defesas. 1. Preliminar. Inépcia da

denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada da conduta atribuída aos acusados, bem como circunstâncias de tempo e local. Preliminar rejeitada. 2. Ilicitude probatória decorrente de instauração da persecução com base em denúncias anônimas. Não ocorrência. Muito embora a denúncia anônima não se preste a fundamentar, com exclusividade, as restrições a direitos fundamentais, nada impede possa ela servir de base para a realização de investigações preliminares voltadas à confirmação daquela notícia. A vedação ao anonimato, consagrada pelo texto constitucional, não pode ser lida de forma absoluta a ponto de tornar imprestáveis todas as notícias apócrifas que são levadas ao conhecimento das autoridades policiais. Doutrina. Precedentes do STF. 3. Hipótese fática em que os policiais receberam denúncia anônima indicando que suspeitos transportavam substâncias entorpecentes em um coletivo. Realização de diligência com o fito de confirmar a informação apócrifa. Identificação dos acusados e efetuação da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes. Ilegalidade não reconhecida. 4. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pela prova técnica. Autoria certa. Relatos convergentes dos policiais civis narrando as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados. Confissão judicial de Larissa, Ariadne, Priscila e Vitória. Revelia da apelante Kelly. Versão inconsistente fornecida por Rafael. Destinação comercial comprovada. 5. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada acima do patamar mínimo. Quantidade expressiva de drogas. Confissão espontânea reconhecida em favor de Ariadne, Priscila, Larissa e Vitória. Reconhecimento da menoridade relativa em favor de Kelly e Ariadne. 6. Causa de aumento prevista pelo art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Necessidade de afastamento. Para a incidência da majorante é imprescindível a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo de transporte coletivo, não sendo suficiente para a caracterização da causa de aumento a mera utilização do coletivo como meio de locomoção. Precedentes do STJ e do STF. Hipótese fática em que os acusados apenas utilizavam do coletivo para transporte das substâncias. 7. Tráfico privilegiado reconhecido em sentença. Ausência de recurso do Ministério Público que impede a o afastamento sob pena de reformatio in pejus. Exorbitante quantidade de drogas. Redução em 1/5 mantida. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Multa fixada proporcionalmente. Detração não aplicada. Prisão preventiva mantida. 8. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500051-68.2020.8.26.0540; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Pires - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022) - grifos nossos.

Assim, apontando todos os relatos dos autos que a droga estava embalada em interior de mochila e com destino a outra cidade, e não havendo venda no transporte público de entorpecentes, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Presente a causa de aumento do tráfico interestadual, art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentando a pena em 1/6, passando para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias, e 546 dias-multa.

Incide, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a

expressão “as penas poderão ser reduzidas”, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, conforme explanado anteriormente, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que a ré faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa. Nesse sentido, em complemento aos arestos já colacionados, seguem os julgados abaixo:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENHIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (STF. RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, que inexistiu prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1776471 MS 2018/0285250-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/3. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 153 kg de cocaína - para elevar a pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 495680 SP 2019/0058485-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício. Demais, a natureza e quantidade da droga já foram consideradas por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA

JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando a ré condenada à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão cumulada com 194 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica a ré AMANDA GONÇALVES PAIVA definitivamente condenada por tráfico privilegiado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias, cumulado com 182 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais

O parágrafo 4^a do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos gravosos. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos, como a ora acusada.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária,

destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016

PENA REGIME FECHADO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA TRÁFICO DE DROGAS SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA EXECUÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a):& Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Esse mesmo entendimento vem sendo seguido pelo STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO

DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA À PENA QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n.126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 3. No caso, a jurisdição das instâncias ordinárias encontra-se encerrada, porquanto na fase de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, verifico que a quantidade de entorpecentes não é expressiva para aplicar a fração em patamar diverso do máximo, com relevo para o fato de que a paciente era menor de 21 anos na data do fato, é primária, está grávida e já está inserida no mercado de trabalho. Assim, o redutor comporta aplicação em seu patamar máximo. 6. Em relação ao regime, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 7. No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi fixado com base na hediondez do delito e na gravidade abstrata da conduta, fundamentos que não são considerados idôneos para fixar o regime mais gravoso. 8. Dessa forma, tratando-se de